

1500051-07.2018.8.26.0001

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LARISSA GASPAS TUNALA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... usuário, mas o local é conhecido ali como ponto de tráfegos.

KEWIN FRANKLYN DA SILVA FERREIRA, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

Diante desse cenário, comprovou-se a materialidade e autoria, notadamente pelo depoimento em juízo das testemunhas, que se coadunam com a prova documental produzida.

E não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara Criminal

Av. Engenheiro Caetano Alvares nº 594, São Paulo - SP - cep 02546-000

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500051-07.2018.8.26.0001

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEWIN FRANKLYN DA SILVA FERREIRA

Juiza de Direito: Dra. LARISSA GASPAS TUNALA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de KEWIN FRANKLYN DA SILVA FERREIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, afirmando que em dia 03 de maio de 2018, às 21 horas, na Rua Condessa Amalia Matarazzo, n. 390, Cachoeirinha, nesta Capital, foi surpreendido por policiais civis trazendo consigo, sem autorização e para uso próprio, 6,9 gramas de substância entorpecente que determina a dependência física ou psíquica, denominada Tetra hidro cannabinoil (THC) - maconha.

Segundo narra a denúncia: "Os policiais civis em atendimento de diligência visualizaram o autor, que ao se deparar com a viatura policial demonstrou nervosismo. Em razão disto, os policiais resolveram abordá-lo e durante a revista pessoal foram encontradas, em suas vestes, três porções de maconha, acondicionadas em saco plástico zipado. Indagado, o autor confessou ser usuário de maconha e que a substância era para consumo pessoal, acrescentando ter pago a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) por cada porção, não informando de quem teria adquirido. A quantidade de drogas e as circunstâncias de sua localização denotam que eram mesmo para uso pessoal do autor."

A decisão de fls. 46 cancelou a audiência preliminar designada, haja vista a impossibilidade de transação penal e a suspensão condicional do processo.

A decisão de fls. 84/85 recebeu a denúncia em 21 de fevereiro de 2019, bem como determinou a citação do réu por edital.

Edital expedido às fls. 90 com publicação às fls. 91.

A decisão de fls. 102 determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, ante a não localização do acusado.

O réu foi citado pessoalmente às fls. 141 em 20.07.2021 e apresentou defesa prévia às fls. 147/151.

A decisão de fls. 162/163 revogou a suspensão do feito e confirmou o recebimento da denúncia.

Laudo definitivo às fls. 225/227.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu, além de manifestar-se pela prescrição.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O topo do artigo 28 da Lei 11.343/06 assim descreve o delito:

" Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo"

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 900061/2018 (fls. 1/2), auto de apreensão/exibição (fls. 6/7), laudo de constatação (fls. 9/11), laudo definitivo (fls. 225/227), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Bruno Maciel de Castro Carvalho, policial civil, disse que se recordou ao ler o boletim de ocorrência. Estava trabalhando para o cartório quando se depararam, na rua, com o réu, que ficou assustado com a viatura. Imaginaram que poderia ser procurado, e por isso foi abordado. Encontraram um pouco de maconha com ele e R\$ 10,00. Ele não estava com documento, disse que foi preso, mas não ficou claro. Ele alegou que era usuário, mas o local é conhecido ali como ponto de tráficos.

KEWIN FRANKLYN DA SILVA FERREIRA, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

Diante desse cenário, comprovou-se a materialidade e autoria, notadamente pelo depoimento em juízo das testemunhas, que se coadunam com a prova documental produzida.

E não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal. Nesse sentido:

"O valor do depoimento de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estaduais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF - HC 73518-5, RELATOR CELSO DE MELLO - DJU 18.10.96, P.39.846).

E, em ambas as fases, confirmou-se a apreensão de drogas na posse do réu, não havendo elementos de mercancia, a indicar a destinação ao uso pessoal.

Em que pesem os argumentos da defesa (fls.147/141) para desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, observa-se que o acusado foi denunciado pelo artigo mencionado e, não, pelo art. 33 da mesma lei. Além do mais, frisa-se a constitucionalidade do delito, conforme explanado pelo Supremo Tribunal Federal, quando apreciou o tema tangencialmente, confirmou a natureza de crime do tipo penal em referência:

EMENTA: I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE 430105 QO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00069 EMENT VOL-02273-04 PP-00729 RB v. 19, n. 523, 2007, p. 17-21 RT v. 96, n. 863, 2007, p. 516-523)

Além do mais, não se aplica, ainda, o princípio da insignificância ao delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que é pressuposto do tipo penal a pouca quantidade, ao passo que a conduta fere a incolumidade pública, alimentando a execução de crimes mais graves como o tráfico de drogas, razão pela qual não pode ser considerado insignificante:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não se aplica o princípio da insignificância nos casos de crime de posse de droga para consumo pessoal, inexistindo, para tanto, diferenciação por tratar-se de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 370.791/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA MEDIDA EDUCATIVA DE 04 MESES DE PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART.

28 DA LEI N.º 11.343/06. INVIABILIDADE. AI NO RESP N.º 1.135.354/PB.

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.

11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância" (RHC 34.466/DF, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 27/05/2013).

2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no RESP 1.135.354/PB, decidiu ser inviável a arguição de questões constitucionais em recurso especial, tendo em vista que a via própria para o exame do pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 43.693/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014)

Na determinação da pena há previsão legal de três sanções: advertência, prestação de serviços à comunidade (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses) e medida de comparecimento a programa ou curso educativo (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses).

Nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06 e, atenta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observada a quantidade e espécie da substância entorpecente apreendida, bem como tratar-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 120/130) entendo que a pena adequada à reprovação de sua conduta é a de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, nos termos do artigo 28, inciso II, c.c. §4º da Lei 11.343/2006.

Por fim, ressalto inexistir a prescrição da pretensão punitiva estatal considerando que houve interrupção da prescrição em 21 de fevereiro de 2019, marco que revela anteriormente não terem transcorridos dois anos. E, após essa interrupção, houve a suspensão na forma do art. 366 do CPP, tendo sido retomada a marcha processual em 06.05.2021. Considerando o prazo anterior transcorrido e este um ano e um mês posterior, vê-se que não houve prazo de 2 anos observados.

Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR KEWIN FRANKLYN DA SILVA FERREIRA à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Em razão da pena aplicada o réu poderá apelar em liberdade, desde que não esteja preso por outro processo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, promovendo-se a liquidação da sanção imposta.

Arbitro os honorários do advogado dativo em 100% do valor da tabela do Convênio OAB/DPE. Expeça-se, oportunamente, a respectiva certidão, intimando-o para retirada.

Em razão do caráter ilícito, decreto o perdimento e a respectiva destruição da substância entorpecente.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

LARISSA GASPAR TUNALA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA